

1500042-91.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a corroborar que se dedica à atividade criminosa em questão, não sendo mesmo merecedor de nenhum benefício legal.

Nesse sentido: "Agravamento regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal.

Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500042-91.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-91.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000112

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO COUTO IRIS RITA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 41/42, que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 15h, na Rua Ernesto C. Santos, no bairro São Francisco, nesta cidade e comarca de São Sebastião, FLAVIO COUTO IRIS RITA, qualificado à fl. 08, trazia consigo, para fins de tráfico, 58 (cinquenta e oito) microtubos de crack, com peso bruto de 43,47 (quarenta e três gramas e quarenta e sete centigramas) ; 17(dezessete) papérolas de cocaína, com peso bruto de 19,98 (dezenove gramas e noventa e oito centigramas); e 16 (dezesseis) papérolas de maconha, com peso bruto de 60,68 (sessenta gramas e sessenta e oito centigramas); além de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11, auto de constatação preliminar de fl. 06 e laudo pericial definitivo de fls. 133/135.

Em razão destes fatos, o réu FLAVIO COUTO IRIS RITA, qualificado à fl. 08, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 69/70), o réu foi citado (fls. 129) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/82). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls.

89/914) e realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o réu foi interrogado. As partes desistiram das testemunhas Natalia Rezende Naves e Gabriel Soares de Oliveira Santos, o que foi homologado (fls. 164/165 e 255/256).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido inserto na denúncia, para que seja condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ao passo que a Defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da lei 11.343/2006. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa e, também, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas, em seu grau máximo. Quanto ao regime, pugnou pela fixação de regime aberto, e, ainda, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a isenção da pena de multa, a aplicação do instituto da detração penal e, por fim, o direito do acusado de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitativa está estampada no auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fl. 11, auto de constatação preliminar de fl. 06, relatório policial de fls. 113/116, laudo químico toxicológico de fls. 82/85 e, ainda, prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

A testemunha Gabriel Soares de Oliveira Santos, em solo policial (fl. 04), narrou que: "Que está com 18 anos e reside na cidade de Ilhabela, no endereço supra declinado; Que desde o Natal esta ficando na casa de sua namorada Bianca que mora no Morro do Abrigo; Que na tarde de hoje subiu o morro a fim de comprar água num bar; Que comprou a garrafinha de água e em seguida foi pedir a um indivíduo desconhecido que estava ali próximo para acender um cigarro; Que seu cigarro foi aceso e logo em seguida surgiram policiais militares; Que nisso, o indivíduo que havia abordado para acender seu cigarro, entrou no bar e o depoente ficou onde estava; Que acabou abordado e revista e nada de ilícito foi encontrado em seu poder; Que o outro indivíduo também foi abordado pelos policiais dentro do bar; Que os policiais encontraram uma sacolinha contendo drogas em seu interior; Afirma que no breve período em que permaneceu por ali, chegou a ver o indivíduo vendendo drogas a moradores que lhe procuravam; Que acabaram os dois trazidos a esta Unidade; Que não conhecia e nunca tinha visto antes o indivíduo que soube chamar-se Flávio; Que o depoente nunca teve problemas com a Justiça, nem enquanto menor de idade; Que esta fazendo bicos de jardinagem com o pai de sua namorada; Afirma que não usa drogas e só fuma cigarros e bebe de vez em quando; Que nega envolvimento com o tráfico de drogas; Que nega ter vendido cinco papелotes de "cocaína" para Flávio aqui presente."

FLAVIO COUTO IRIS RITA, em solo policial (fl. 05), narrou: "[...] Que nega estar traficando na tarde de hoje; Que reside no bairro Topolândia e nesta tarde dirigiu-se ao Morro do Abrigo, eis que havia combinado com uma garota de nome Tauane de se encontrarem, num barzinho, por volta das 15h30min; Que então rumou para o citado bar, de "uma tiazinha" a fim de aguardá-la; Que antes contudo havia abordado um indivíduo nas proximidades, que aqui soube chamar-se Gabriel Soares de Oliveira Santos que estava vendendo drogas ali mais pra baixo; Que adquiriu dele, cinco porções de "cocaína" ao preço de R\$ 10,00 (dez reais) cada; Na sequência, dirigiu-se ao barzinho, onde passou a consumir latinhas de cerveja; Que havia consumido umas seis latinhas de cerveja e também consumido as cinco porções de cocaína adquiridas e permanecia aguardando; Que havia ido em poder de R\$ 100,00 (cem reais)

e após gastar cinquenta com a cocaína, restava ainda cinquenta reais em seu poder; Que estava sozinho, ocupando uma mesa do lado de fora do bar, quando se aproximaram policiais militares que acabaram lhe abordando; Que depois acabou conduzido a esta Unidade; Que nega ter dispensado porções de drogas diante da chegada de policiais militares ao local; Que o rapaz que lhe vendeu as drogas também foi trazido a esta Unidade, mas não ficou preso; Que o interrogado afirma trabalhar como puxador de praia, ou seja, angaria clientes na praia para consumir em um quiosque; Afirma que largou o crime e esta tentando reconstruir sua vida."

FLAVIO COUTO IRIS RITA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Narrou, em síntese, que estava na cidade por conta da temporada, sendo que sua cidade de origem é Taubaté/SP; no dia anterior aos fatos, conheceu uma garota em Ilhabela e marcou com ela de se encontrarem no dia seguinte, em um bar; admitiu que é usuário contumaz de entorpecentes e que enquanto aguardava a garota fez uso de cocaína, a qual adquiriu com a pessoa de Gabriel (fl. 04); admitiu que se assustou com a chegada dos policiais e que correu para o interior do bar; não trazia nada de ilícito consigo, sendo que as drogas foram apresentadas pelos policiais posteriormente; não conhecia os policiais que o abordaram e não soube explicar o motivo pelo qual estão lhe acusando injustamente. Ao Ministério Público respondeu: pretendia ficar na cidade cinco dias; é pensionista e não estava trabalhando na ocasião dos fatos.

Noutro giro, o Policial Militar, Everton Emanuel Barbosa, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: na data dos fatos estava de serviço e foi comunicado via Copom sobre uma denúncia de que dois indivíduos e as características de suas vestes (bermudas) estariam traficando drogas, no bairro Morro do Abrigo; dirigiram-se ao local da denúncia e ao se aproximarem avistaram dois indivíduos de bermuda, conforme denunciado; viu o réu Flavio dispensar uma sacola plástica e correr para dentro do bar; o outro indivíduo - Gabriel - estava na calçada; Flávio não confessou a prática delitiva, porém, Gabriel - que não trazia consigo nada de ilícito - informou que presenciou o réu Flávio comercializando drogas no local; tem certeza que a sacola plástica foi dispensada pelo réu Flávio e continha 58 pedras de "Crack", 17 papelotes de "cocaína" e 16 trouxinhas de "maconha"; em poder de Flávio ainda foi encontrada a importância de R\$ 50,00. A Defensora respondeu: com Gabriel nada de ilícito foi encontrado e ele também foi conduzido à Delegacia.

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

Pois bem.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. O réu negou a traficância, bem como tentou imputar ao transeunte Gabriel a propriedade das drogas e que ele seria na verdade o traficante. Disse que estava na cidade com a suposta esposa, mas ela não compareceu em juízo para confirmar sua versão, tampouco, a garota que disse ter conhecido em Ilhabela. Nada trouxe elementos para infirmar os relatos oferecidos pela testemunha policial e tampouco comprovou atividade lícita. As exculpatórias apresentadas em Juízo, além de previsíveis e bem pouco consistentes, restaram isoladas nos autos, desacompanhadas de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutadas cabalmente pela prova adversa notadamente o firme relato da testemunha policial, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante levada a efeito, comprometendo sobremaneira o réu.

Em verdade, o que restou configurado foi que o réu - que ostenta inúmeras passagens pela vara da infância por delito análogo -, veio de Taubaté comercializar entorpecentes, aproveitando-se da alta temporada e do grande fluxo de pessoas. Portanto, a negativa apresentada pelo acusado está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Senão vejamos:

A testemunha Gabriel, em solo policial (fl. 04), informou não possuir passagens

criminais, tampouco respondeu por atos infracionais e, ainda, que não é usuário de drogas e que estava no local comprovando água, momento em que presenciado o acusado "vendendo drogas a moradores que lhe procuravam". Tal testemunha (que não correu; que não trazia nada de ilícito consigo; que não foi flagrado pelos policiais dispensando produtos ilícitos; que não possui histórico criminal) não tinha qualquer motivo para incriminá-lo, já que sequer o conhecia.

Nesse sentido, o PM Barbosa, em juízo, confirmou a versão apresentada na fase inquisitiva, bem como relatou que após receberem denúncias noticiando tráfico de drogas pelo local, rumaram ao endereço informado e lá chegando visualizaram o réu, além de dispensar uma sacola plástica contendo drogas, tentar empreender fuga; confirmou que a testemunha Gabriel relatou ter presenciado o réu comercializando drogas no local.

O policial prestou depoimento coeso, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e goza de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seu depoimento constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação. Ademais, seus relatos estão em consonância aos oferecidos na fase investigativa, sem divergir aos prestados por seu colega de farda.

Vê-se, pois, que os depoimentos das testemunhas, ouvidas na fase investigativa e em juízo, confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. Frise-se que o réu não trouxe qualquer comprovação de sua suposta dependência por drogas, tampouco arrolou testemunhas a fim de corroborar sua frágil versão ou para infirmar os seguros e coesos relatos do policial militar. Por derradeiro, três tipos de drogas foram apreendidas na posse do réu, enfraquecendo ainda mais o já debilitado e inverossímil argumento de que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal.

Saliente-se que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, observo que o réu possui várias passagens por atos infracionais (fls. 37/38) e considerando o posicionamento prevalente no

sentido de que os atos infracionais não podem ser valorados como maus antecedentes, já que não são crimes e, assim, não podem repercutir na vida do agente como se o fossem fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Nesta fase ainda, desfavoráveis às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a quantidade da droga traficada, bem como a diversidade e a natureza da droga (58 microtubos de crack, com 43,47 gramas; 17 papélotes de cocaína, com 19,98 gramas e 16 papélotes de maconha, com 60,68 gramas), de modo que deve ser levada em conta para a fixação da pena base nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, assim, exaspero em 1/6 a pena anteriormente fixada, para resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a atenuante da menoridade relativa, pois o réu ao tempo do crime possuía 20 anos de idade (fl. 08 e 22), motivo pelo qual retorno a pena ao patamar inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o réu, apesar da tenra idade e ser tecnicamente primário na esfera criminal (fls. 36), ostenta numerosas ocorrências infracionais originárias das comarcas de Taubaté e Tremembé, conforme indica a certidão de fls. 37/38, tendo sido inclusive já submetido a medida socioeducativa por representação julgada procedente nos autos de nº 0002169-42.2016.8.26.0634, da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Tremembé/SP, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a corroborar que se dedica à atividade criminosa em questão, não sendo mesmo merecedor de nenhum benefício legal.

Nesse sentido: "Agravamento regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravamento regimental não provido." (STF -1ª Turma - RHC 190434 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe em: 16/11/2021).

Ainda: "O histórico de ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração." (STJ - 3ª Turma - EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, DJe em: 04/10/2021).

Outrossim, como dito, o réu já foi submetido à medida socioeducativa por representação julgada procedente nos autos de nº 0002169-42.2016.8.26.0634, da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Tremembé/SP, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Incabível, assim, o privilégio.

Por esses motivos, ausente o requisito de "não se dedicar a atividade criminosa", não é o caso de aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Mantida, portanto, a pena fixada na primeira fase de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a qual torna definitiva.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial semiaberto (artigo 33, §2º, "b", CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena. Ademais, a quantidade de droga, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância. No entanto, a pena é superior a quatro anos e inferior a oito e, por outro lado, conforme exposto, o réu vinha reiterando nas atividades criminosas, o que justifica a eleição do regime intermediário.

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em razão do quantum de pena aplicada (Art. 44, I, CP). Pelos mesmo motivo, não há

que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, caput, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu FLAVIO COUTO IRIS RITA, qualificado à fl. 08, às pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Diante do regime aplicado, semiaberto, desproporcional a manutenção do acusado em restrição de liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário' (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). Voto da ministra Cármen Lúcia concedeu a ordem por considerar evidente o constrangimento ilegal, expondo que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020).

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se edital para a sua intimação, com prazo de 90 dias, bem como o necessário quanto às drogas.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

Cumpra-se.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA